

1502025-03.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR DAMASCENO CARVALHO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual JOÃO VITOR DAMASCENO CARVALHO e SAMUEL MOURA VOLPATO, foram denunciados como incursores, por duas vezes, nas penas do artigo 157, § ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1502025-03.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502025-03.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR DAMASCENO CARVALHO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual JOÃO VITOR DAMASCENO CARVALHO e SAMUEL MOURA VOLPATO, foram denunciados como incursores, por duas vezes, nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II, na forma dos artigos 29 e 70, todos do Código Penal.

Narra a denúncia (fls. 89/92) que, no dia 02 de setembro de 2021, às 02h32min, na Rua Arinos, 620, Industrial Anhanguera, nesta cidade e comarca de Osasco, os acusados, qualificados às fls. 12/13 E 14/15, respectivamente, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça, a qual reduziu a vítima Wellington Severino de Moura à impossibilidade de resistência, para proveito comum, a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais), 02 (dois) celulares, marca Motorola, a carteira com documentos pessoais e cartões bancários, pertencentes à aludida vítima, e o veículo, marca Renault, modelo Kwid Zen, placas QUV6496/Belo Horizonte-MG, pertencente à vítima Emily das Graças Gomes.

Segundo o apurado, na data dos fatos, os denunciados solicitaram o serviço de transporte por meio de aplicativo e, ao entrarem no veículo, o denunciado JOÃO VICTOR anunciou o roubo, gritando: "Perdeu, perdeu", e encostou um objeto não identificado na cintura da vítima Wellington, motorista do veículo.

Nesse momento, os denunciados exigiram que a vítima estacionasse o veículo e o denunciado SAMUEL a indagou: "Cadê o dinheiro?". Em seguida, os denunciados subtraíram os celulares, o dinheiro e a carteira da vítima Wellington, a qual obedeceu a ordem para sair do veículo e, então, os denunciados deixaram o local na posse do veículo.

Os policiais militares estavam em patrulhamento ostensivo, quando receberam notícia referente a dois indivíduos que realizavam o desmanche de um veículo na via pública e, então, se dirigiram ao local. Na ocasião, um dos denunciados, ao avistar a viatura da polícia, tentou se evadir, mas não obteve êxito e foi detido. Indagados, os denunciados afirmaram que pretendiam desmanchar o veículo. Devido a suspeita quanto à origem espúria do veículo, os denunciados foram conduzidos à delegacia de polícia, onde se constatou que o veículo havia sido roubado.

Em sede policial, a vítima Wellington, após descrever os sinais característicos dos roubadores, reconheceu, sem dúvidas, os denunciados como autores do delito.

A denúncia foi recebida às fls. 134/136.

Citados às fls. 157 e 159/160, os acusados apresentaram resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 164/167).

Em decisão às fls. 179/182 foi indeferido o pedido de liberdade provisória formulado, mantendo a prisão dos réus. Na mesma oportunidade, o recebimento da denúncia foi mantido e a audiência de instrução, debates e julgamento virtual foi designada para o dia 12.01.2022, às 13h30.

Em audiência de instrução realizada em 12.01.2022 (fls. 220/224), foram ouvidas as testemunhas Joercio, Marcelo e a vítima Emily. No mesmo ato, foi deferido pedido de liberdade provisória em favor dos réus.

Alvará de soltura de JOÃO VITOR DAMASCENO CARVALHO às fls. 234/236 e alvará de soltura de SAMUEL MOURA VOLPATO cumprido às fls. 241/243.

Folha de antecedentes às fls. 264/266 e 267/269 e certidões de distribuição criminal às fls. 139 e 142/143.

Em nova audiência os réus foram interrogados.

Em memoriais, a acusação, em preliminar, pediu a nulidade do feito diante de um suposto cerceamento da acusação diante da negativa de condução coercitiva. No mérito, pediu a condenação nos termos da inicial.

Em memoriais, a Defesa de Samuel pediu a absolvição diante da ausência de provas,

especialmente pela ausência da vítima e o irregular reconhecimento.

Em memoriais da Defesa de João Vitor pediu a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a receptação.

É relatório.

Fundamento e decido.

I – Preliminar aventada pelo Ministério Público.

Pleiteia o Ministério Público a nulidade do feito diante do indeferimento da condução coercitiva da vítima.

O pedido deve ser indeferimento por três fundamentos em essência: a) houve inequívoca preclusão relativamente a tal pedido; b) houve violação a boa-fé objetiva processual eis que foi o próprio representante do Ministério Público quem desistiu da oitiva da vítima; c) a condução coercitiva, nos moldes em que desenhada hoje pelo sistema jurídico, especialmente diante dos contornos da lei de abuso de autoridade, representa, não atendidos os pressupostos legais, violência por parte do Estado.

i.a.) Quanto à preclusão. Verifica-se dos autos que na audiência de instrução de fls. 220/224, a vítima Wellington, regularmente intimada (fls. 215), não compareceu. Nesta oportunidade, por parte deste Magistrado, foi indeferida sua condução coercitiva.

O representante do Ministério Público, na oportunidade, não apresentou qualquer pedido ou mesmo “recurso do indeferimento”.

Em nova audiência de instrução, o subscritor do agora “pedido de nulidade” DESISTIU DA OITIVA DA VÍTIMA (fls. 248). Referido pedido foi devidamente HOMOLOGADO pelo juízo.

Assim, tem-se que houve inequívoca preclusão lógica. A preclusão representa a perda, a extinção ou a consumação de uma faculdade processual pelo fato de ter atingido os limites prescritos a seu exercício. No caso, o pedido de condução coercitiva, em verdade, de um ato processual, neste momento do desenvolvimento do procedimento, depois das audiências pretéritas, revela-se incompatível com a própria posição processual do Ministério Público, o qual assentiu com a designação de nova audiência, como fora feito, sem a necessidade da aludida medida constritiva. Assim, no plano processual não há falar em deferimento, agora, de condução coercitiva.

i.b) Também tem-se que a posição do subscritor representante do Ministério Público viola a boa-fé objetiva processual na dimensão do venire contra factum proprium, na medida em que fora o próprio Ministério Público quem, além de não se opor ao indeferimento, assentiu e desistiu da oitiva da vítima. A oitiva da vítima, agora, representaria, aí sim, violação ao direito de defesa e ao devido processo legal na vertente da igualdade de armas e oportunidades entre acusação e defesa.

i-c) Não fosse pelos motivos processuais anteriores, tenho que a medida de condução coercitiva mostra-se incompatível com o modelo de processo penal escolhido pelo legislador. Explico.

Em primeiro lugar, o legislador, com legitimidade democrática, político-criminalmente, por meio da Lei n. 13.964/19, especificamente no art. 3º-A, escolheu o modelo de processo penal de “estrutura acusatória” o que significa que o juiz não pode se substituir às partes e, no caso da condução coercitiva, deve o Ministério

Público trazer aos autos o motivo - o qual deve ser injusto - do não comparecimento da testemunha e/ou vítima a juízo.

Em segundo lugar, e na esteira do ponto anterior, ao editar a Lei de Abuso de Autoridade (Lei n. 13.869/2019), notadamente no art. 15-A (violência institucional) o legislador claramente fez uma escolha político criminal, qual seja, privilegiou a proteção dos direitos individuais destes sujeitos passivos em detrimento a busca frenética por um processo penal eficaz. No "catálogo" de comportamentos proibidos aos sujeitos ativos (agentes públicos - art. 2º), o legislador estabeleceu limites éticos-jurídicos que não podem ser desconsiderados. E mais, estes limites éticos-jurídicos devem ser compatibilizados tanto em relação às disposições processuais em vigor, como em relação ao modelo de processo penal acusatório. Ambos, repita-se, escolha do legislador.

Em terceiro lugar, de rigor salientar que a vítima, regularmente intimada não compareceu. Assim, conclui-se desde já que, provavelmente, optou a vítima por não mais relatar os fatos. Esta vontade deve ser observada pelo Estado.

Em quarto lugar, o sistema criminal foi forjado no entorno da proteção de direitos individuais do investigado e/ou acusado. Não há dúvida que tais direitos, para correta aplicação da lei, devem ser observados. Contudo, não obstante a proteção do acusado contra o Poder jurídico de punir do Estado, a vítima, no processo criminal, vem ganhando papel de destaque e cumpre ao juiz o dever de proteger os direitos do ofendido, inclusive o de não depor em juízo.

Em quinto lugar, cumpre anotar que o art. 201 do CPP dispõe que a oitiva da vítima no processo penal deve ser realizada "sempre que possível".

Em sexto lugar, embora o depoimento da vítima seja essencial em juízo, especialmente quando se trata de delito praticado exatamente contra a própria vítima, como é o crime objeto do presente processo, não é ela obrigada a dizer a verdade.

Em sétimo lugar, em que pese ter o Ministério Público desistido da vítima, não trouxe aos autos, ônus que lhe cabe, qual teria sido o motivo da ausência da vítima, vale dizer, se este fora justo ou injusto. O artigo 201, §º exige para a condução coercitiva, dois pressupostos: a) regular intimação; b) ausência sem motivo justo. O Ministério Público, ao qual incumbe o ônus da prova, não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre que o não comparecimento da vítima fora injusto. Poderia o Ministério Público, por meio de seu quadro de funcionários, perquirir o motivo do não comparecimento, entretanto assim não o fez. Veja-se que são dois os pressupostos e do simples não comparecimento após intimação não se pode presumir a justiça ou injustiça.

Em oitavo lugar, referido quadro demanda o respeito pela opção da vítima. É dever do Magistrado velar e zelar para que não haja uma revitimização por conta da oitiva em juízo. Com efeito, não é dado ao Estado-juiz compelir a vítima a comparecer em juízo para depor quando ela não é compelida a falar a verdade e, ademais, pode simplesmente dizer que não se recorda dos fatos.

No plano internacional, cumpre anotar que a Declaração dos princípios básicos de justiça relativos às vítimas da criminalidade e de abuso de poder de 1985, adotada pela resolução 40/34 de 29.11.1985 da assembleia geral das Nações Unidas, dispõe, no art. 4 do anexo, que "as vítimas devem ser tratadas com compaixão e respeito pela sua dignidade. Têm direito ao acesso às instâncias judiciárias e a uma rápida reparação do prejuízo por si sofrido, de acordo com o disposto na legislação nacional."

A esse respeito, reforce-se que o Conselho Nacional de Justiça editou ato normativo

recomendando aos órgãos do Poder Judiciário, dentre outras coisas, a observância dos tratados internacionais de direitos humanos: ATO NORMATIVO. RECOMENDAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. USO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. ATO APROVADO (CNJ - ATO - Ato Normativo - 0008759-45.2021.2.00.0000 - Rel. FLÁVIA PESSOA - 61ª Sessão Extraordinária - julgado em 14/12/2021).

Além disso, o art. 1º da Resolução 253/2018 do Conselho Nacional de Justiça impõe a todos os Magistrados o dever de, no exercício jurisdicional, adotar as providências necessárias para garantir que as vítimas de crimes sejam tratadas com equidade, dignidade e respeito pelos órgãos judiciários e seus serviços auxiliares.

Assim, percebe-se que a preocupação com os direitos das vítimas tem amparo e proteção multinível e qualquer ato jurisdicional não pode ser ofensivo à dignidade e respeito.

Não se desconhece a preocupação do membro do Ministério Público na angariação de provas para fins de instruir processo penal, entretanto, eventual imposição do Magistrado em obrigar o comparecimento da vítima representaria indevida violência psicológica e institucional, especialmente porque ciente da audiência optou por não comparecer.

Destarte, em um juízo de ponderação entre, de um lado, a colheita do depoimento da vítima, e, portanto, garantir-se a eficiência do sistema penal e, de outro, a preservação da saúde, dignidade e respeito da vítima -, estes direitos devem prevalecer, sob pena que haver uma nova vitimização no processo penal, como, aliás, foi a opção político criminal do legislador.

Na mesma toada, a Lei 14.245/21 (Lei Mariana Ferrer) introduziu em diversas leis, inclusive no CPP, dispositivos que objetivam zelar pela integridade física e psicológica da vítima, com o mesmo objetivo de evitar a revitimização, isto é, a submissão a nova violência, seja pelo Estado, seja pelos demais participantes do processo penal, sob pena de responsabilização nas esferas civil, penal e administrativa. Atribui-se, ainda, ao magistrado, o dever garantir o cumprimento do novo regramento legal.

Por fim, digna de nota, ainda, é a introdução do art. 15-A na Lei de Crimes de Abuso de Autoridade, o qual, na mesma sequência de ideias acima exposta, tipificou o delito de violência institucional, in verbis: Art. 15-A. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem estrita necessidade: I - a situação de violência; ou II - outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. § 1º Se o agente público permitir que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena aumentada de 2/3 (dois terços). § 2º Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro.

Portanto, não sendo trazido pela acusação qualquer elemento que indique que a vítima ainda tenha vontade de depor ou que sua vontade esteja coarctada, há que se preservar o melhor interesse da vítima, respaldado por toda a ordem jurídica, nacional e internacional, nos moldes acima expostos, evitando-se a sua revitimização ou vitimização secundária.

II - Quanto ao mérito

O pedido é improcedente.

Em que pese a materialidade esteja demonstrada nos autos por meio do boletim de

ocorrência de fls. 18/23 e auto de exibição e apreensão (fls. 24), a autoria não está demonstrada nos autos de forma indubitosa.

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória não é suficiente à comprovação da autoria delitiva para além da dúvida razoável, devendo, portanto, prevalecer o postulado da presunção e inocência pelos motivos que passo a expor.

Com efeito, a finalidade epistêmica do processo penal é a busca da verdade, ainda que de forma aproximada, por meio de reconstrução fática que leve à superação do postulado da presunção de inocência. Entretanto, este objetivo teleológico deve ser buscado com respeito às regras legais e constitucionais de produção e valoração das provas. Nesse sentido: “assim, no Brasil, os códigos processuais, civil e penal, dispõem justamente acerca da validade da prova da verdade, que deverá seguir um trâmite que não cause surpresa às partes (livre acesso), que amplie sua participação no discurso relacionado ao seu enunciado (contraditório), que seja adequada e idônea ao fato que se quer provar e que não seja obtida por meios ilícitos. A busca da verdade não é, assim, orientada para a obtenção da verdade substancial, mas apenas da verdade provavelmente admitida. Não vigora mais, assim, no processo a busca da verdade real. Até porque, como já se disse, não existe essa suposta verdade real. Seria uma pretensão audaciosa do direito entender que o juízo possa fazê-lo unicamente pelos instrumentos legais.” (TAVARES, Juarez, CASARA, Rubens. Prova e verdade. 1ª ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020, p. 147).

Cumprido pontuar, nesse prisma, que o Código de Processo Penal adotou o sistema do livre convencimento objetivo motivado do juiz, pelo qual incumbe ao magistrado formar sua convicção a partir da livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, desde que fundamentadamente.

Uma das regras legais de valoração racional da prova vem insculpida no art. 155 do CPP. Este comando legal, a seu turno, estabelece limites ao livre convencimento objetivo do juiz, na medida em que dispõe que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em outras palavras, não é lícito ao julgador formar sua convicção e, por conseguinte, proferir sentença condenatória com base em elementos indiciários, colhidos em sede inquisitorial. É preciso que, quanto às provas orais, sejam elas avaliadas em contraditório judicial.

No caso dos autos, as provas são eminentemente orais e não houve a produção de prova – sujeita ao crivo do contraditório – que permita a demonstração, para além de qualquer dúvida racional-objetiva, da premissa fática da acusação, qual seja: no dia 02 de setembro de 2021, às 02h32min, na Rua Arinos, 620, Industrial Anhanguera, nesta cidade e comarca de Osasco, os acusados, qualificados às fls. 12/13 E 14/15, respectivamente, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, mediante grave ameaça, a qual reduziu a vítima Wellington Severino de Moura à impossibilidade de resistência, para proveito comum, a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais), 02 (dois) celulares, marca Motorola, a carteira com documentos pessoais e cartões bancários, pertencentes à aludida vítima, e o veículo, marca Renault, modelo Kwid Zen, placas QUV6496/Belo Horizonte- MG, pertencente à vítima Emily das Graças Gomes.

Em juízo os réus negaram os fatos. Ambos apresentaram versões coerentes. Afirmaram que estavam na favela quando a pessoa de nome Maciel ofereceu um valor para buscarem um carro. Esta pessoa disse que se não fosse possível pegar o carro era para somente levar a bateria. Estavam no local, com o capô aberto, quando apareceu a viatura de polícia. João Vitor afirmou que no momento “se rendeu” e estava dentro

do carro. Samuel, por sua vez, que estava mexendo na bateria, tentou correr mas desistiu e foi alcançado.

As provas produzidas em juízo não refutam, para além de qualquer dúvida razoável, a versão dos réus. Assim, deve prevalecer o postulado da presunção de inocência com a consequente absolvição.

A vítima direta dos fatos não foi ouvida em juízo, tendo em vista a desistência do Ministério Público.

A vítima Emily, por sua vez, apenas comprovou ser a proprietária do veículo e que não estava no local.

A testemunha Joercio confirmou que os réus, no momento, estavam mexendo no carro.

Analisando-se a prova, tem-se que, embora a vítima tenha feito o reconhecimento na Delegacia de Polícia – reconhecimento este irregular e sem qualquer formalidade –, em juízo não fora ouvida.

A única prova, produzida na fase de inquérito, sem reprodução em juízo, não traz qualquer segurança epistemológica.

No reconhecimento os réus estavam sozinhos.

Assim, diante da irregularidade do reconhecimento na fase policial e das inconsistências em juízo, e da linha tênue de certeza para condenação, por si só, a absolvição já se impõe.

No atual avanço do processo penal não se pode ignorar regras de procedimento, como fora feito pelo Delegado de Polícia. Outrossim, não se pode ter como certeza um reconhecimento quando este não minimamente corroborado, sequer pela própria vítima.

Sobre o reconhecimento, importantes julgados recentes: STJ - HC 598886 / SC - Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ - 6ª T - j. 27.10.2020 - DJe 18/12/2020; STJ - HC 652284 / SC - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - 5ª T - j. 27.04.2021 - DJe 03/05/2021; TJSP - Apelação Criminal n. 1509490-21.2020.8.26.0050 - Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli - 16ª Câmara de Direito Criminal - j. 01.06.2021 - publicação 01.06.2021)

Nesse sentido também em recente ponderação sobre o reconhecimento durante a fase de inquérito policial e a interpretação do art. 226 do CPP: "Esta Corte Superior inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no HC 691.549/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

Portanto, em juízo não foi possível o escrutínio corroborativo da prova testemunhal que levasse a uma reconstrução fática aproximativa das premissas afirmadas na inicial.

A única certeza que se tem dos autos é que a vítima tivera o bem subtraído.

O direito penal, frise-se, não se contenta com conjecturas, nem mesmo com probabilidade de autoria. A moderna dogmática penal e processual penal exige a convicção plena do julgador, base ética indeclinável amparada em substrato material valorativo produzido em contraditório. Em outras palavras, a dúvida, por menor que seja, milita sempre em favor do acusado, eis que a presunção de inocência é corolário de um Estado de direito democrático.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente ação penal e ABSOLVO os acusados JOÃO VITOR DAMASCENO CARVALHO e SAMUEL MOURA VOLPATÓ da acusação de terem infringido o artigo 157, § 2º, incisos II, na forma dos artigos 29 e 70, todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, façam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Osasco, 09 de novembro de 2022.